

0000873-14.2018.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... direitos, uma vez que é reincidente pela prática de tráfico (fls. 124) e ostenta condenações posteriores, o que demonstra que não foi um fato isolado em sua vida e que não teria responsabilidade para cumprir o benefício, o mesmo ocorrendo em relação à substituição por multa. Incabível a concessão de "sursis" por ser reincidente em crime doloso (art. 77, inc. I, do Código Penal).

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

0000873-14.2018.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000873-14.2018.8.26.0537 2018/001015

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Huenos Gaspari Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

HUENOS GASPARI LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, § 1.º e § 4.º, incisos II e IV c.c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, porque no dia 14 de maio de 2018, por volta das 00:50 horas, na Avenida Doutor Ulisses Guimarães, n.º 196, Bairro Conceição, agindo em concurso, previamente ajustado e com unidade de desígnios e divisão de tarefas com outro homem não identificado, durante o repouso noturno e mediante escalada, tentou subtrair, mediante escalada, para proveito comum, bens pertencentes à vítima Izael Coutinho da Silva, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Foi concedida liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares, na audiência de custódia (fls. 77/79).

Recebida a denúncia em 22.11.18 (fls. 97), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 158/159). Na instrução criminal foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo desistência quanto às faltantes, sendo o réu interrogado.

Após a fase do art. 402 do Código de Processo

Penal, a Dr.^a Promotora de requereu a procedência parcial da ação, afastando-se o repouso noturno, com aumento da pena pela reincidência, diminuição pela tentativa de metade, fixação de regime semiaberto, afastando-se as substituições legais e vedado o direito de recorrer em liberdade.

O Dr. Defensor Público requereu a absolvição por atipicidade (por ausência de materialidade, pois não há narrativa de quais bens tentou furtar) ou em caso de eventual condenação a desclassificação para violação de domicílio e em caso de condenação a fixação de regime aberto e substituição de pena restritiva ou multa.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 07), o acusado confessou a prática do crime. Disse que estava com outro homem, que este pulou para dentro da obra para furtar materiais de construção, e que ficou do lado de fora, esperando para ajuda-lo. Falou que após "ouvir barulhos" o homem pulou o muro e saiu correndo sem lhe entregar nada. Negou-se a informar nome e dados qualitativos do homem que se evadiu. Narrou que foi agredido por Izael e Lucas.

Em juízo, permaneceu calado. Nada tem contra vítima e os policiais.

A vítima, na fase extrajudicial (fls. 05), disse que estava realizando uma construção ao lado de sua residência. Relatou que ouviu um barulho estranho advindo da obra, aparentando ser de alguma pessoa no local. Narrou que foi verificar o que ocorria, acendeu a luz e o cachorro começou a latir, momento em que um homem pulou muro. Falou que correu atrás do homem, mas não conseguiu alcançá-lo. Afirmou que seu sobrinho Lucas viu o réu pulando o muro e o segurou. Esclareceu que nada foi subtraído da obra. Negou que ele ou Lucas tenham agredido o réu.

Em juízo, declarou que ouviu barulho na parte do imóvel que estava em construção, viu dois homens que foram um para cada lado. Informou que viu um homem pulando o muro, indo atrás do mesmo e conseguiu alcançá-lo. Narrou que foram subtraídos diversos bens do local, mas não pode dizer se foi nesta data. Apenas nesta vez conseguiu abordar o réu.

Lucas, na fase extrajudicial (fls. 06), relatou que ouviu um barulho estranho vindo do imóvel em obras pertencente ao tio Izael, que aparentava indicar alguma pessoa no local. Narrou que Izael foi até o imóvel e acendeu a luz, momento em que o cachorro começou a latir e um homem desconhecido pulou o muro. Falou que Izael saiu correndo atrás do homem, mas não conseguiu alcançá-lo. Disse que viu outro homem (réu), pulando o muro, e segurou-o na sequência. Informou que nada foi subtraído do local. Negou que ele ou Izael tenham agredido o réu.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 03/04), disseram que receberam informe via rádio de que um homem havia rendido outro, na via pública, por tentativa de furto a uma obra. Afirmaram que no local dos fatos encontraram Izael, proprietário da obra, e Lucas, sobrinho dele, rendendo o acusado. Informaram que Izael relatou que um homem havia pulado o muro do imóvel que estava em obras e que saiu correndo atrás daquele, mas não o alcançou. Contudo, o sobrinho Lucas viu o réu pulando o muro e o deteve. Informaram que não localizaram nada de ilícito na posse do réu. Wilton (policial), em juízo, narrou que quando chegaram ao local o réu já estava abordado pela vítima. Acha que o outro homem que estava com o réu se evadiu. Não lembra da versão do réu, nem se havia bens separados. Reconheceu sua assinatura a fls. 04.

O policial Anderson não foi ouvido em juízo, por estar em férias (fls. 199), bem como a testemunha Lucas, tendo as partes desistido de suas oitivas.

O fato das testemunhas serem policiais não as torna impedidas ou suspeitas (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.^a Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 24).

Não é caso de absolvição por atipicidade, posto que houve confissão extrajudicial do réu que pretendia furtar materiais de construção e a vítima informou que o havia obra no local (em construção), pelo que o fato de não ter pegado bens, implica apenas em ser considerado na redução da pena pela tentativa.

Inviável a desclassificação para invasão de domicílio, posto que o dolo do réu era de furtar materiais de construção.

Assim, considerando a confissão extrajudicial, que o acusado foi detido pela vítima e testemunha no local dos fatos, os depoimentos das testemunhas é caso de condenação.

A qualificadora da escalada está demonstrada pela prova oral produzida e pelo laudo pericial (fls. 110/114), o qual constatou que o provável meio de acesso do réu ao interior do imóvel se deu por meio de escalada do portão, de 2 metros de altura, que o guarnecia (fls. 112).

O concurso de agentes está demonstrado, pois a prova produzida é no sentido de que o crime foi praticado pelo réu e por outro homem não identificado, que juntos tentaram subtrair os materiais de construção do imóvel em obras, mas foram impedidos pela chegada da vítima e do sobrinho desta, que perceberam a presença de pessoas no local.

Fica afastada a aplicação da causa especial de aumento do § 1.º do art. 155, pois incompatível com o furto na modalidade qualificada, sendo aplicável apenas à figura simples.

Nesse sentido:

"Apelação criminal. Furto qualificado e corrupção de menores. Primeira figura marcada pelo concurso de agentes e emprego de chave falsa. Condenação sequer impugnada no apelo, que fica mantida. Recurso voltado contra as penas. Pertinência do pleito com vistas à redução. Excessos na fixação da base, com indevida valoração de condenações não definitivas, bem como no índice de aumento cominado à reincidência (1/4), por demais rigoroso. Furto. Causa de aumento de pena do art. 155, § 1.º, do CP. Crime praticado durante o repouso noturno. Inaplicabilidade, tratando-se de delito qualificado na forma do § 4º. Suficiência dos limites máximo e mínimo de punição previstos para o furto qualificado. Figura majorada reservada às hipóteses de furto simples. Precedentes. Majorante afastada. Apelo provido para afastar a majorante e, nos termos da fundamentação, reduzir as penas." (TJ-SP - APL: 00001689720148260620 SP 0000168-97.2014.8.26.0620, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 03/08/2015, 2.^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/08/2015)

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pela escalada praticado em repouso noturno - Artigo 155, § 1.º e § 4.º, inciso II, do Código Penal - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e Materialidade comprovadas - Palavra das vítimas - Prova testemunhal - Prova pericial - Confissão espontânea - O fato de o acusado ter confessado sua autoria, bem como se demonstrar arrependido, não conduz à absolvição - Afastamento da causa de aumento do artigo 155, § 1º, do Código Penal - Necessidade - Causa de aumento incompatível com o furto na modalidade qualificada, sendo aplicável apenas à figura simples - Redução da reprimenda - APELO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJ-SP - APL: 00025885420148260627 SP 0002588-54.2014.8.26.0627, Relator: Silmar Fernandes, Data de Julgamento: 16/03/2016, 3.^a Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 18/03/2016).

Assim, impõe-se a condenação do acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 202/203 - proc. 38058-15.2012 - pena julgada extinta em 20.01.17 - fls. 142) e possui duas condenações posteriores ao crime em comento (fls. 202 - proc. 4183-78.2017 - transitou para o réu em 07.10.19; fls. 203 - proc. 1501402-51.2021.8.26.0537), de forma que não podem ser consideradas para quais fins.

Nesse sentido:

"Na colocação da pena-base não pode o Magistrado considerar, para situá-la acima do mínimo legal, circunstâncias posteriores ao fato em causa ou com ele

contemporâneas, tais como, por exemplo, outras condenações impostas ao acusado em diferentes processos que tenham tido o desate após o crime ventilado no feito (JUTACRIM 45/221). No mesmo sentido, TACRSP: JTACRIM 29/356, 30/414" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 334). Levando em conta as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, à razão mínima, em face da situação econômica do acusado.

Compenso a reincidência e a confissão extrajudicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.^a Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito recente decisão do STJ:

Processo

AgRg no Resp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do ERESP n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Diminuo a pena de 1/2 levando em conta o "iter criminis" percorrido, posto que foi surpreendido pela vítima e testemunha quando já havia ingressado no imóvel em obra onde pretendia furtar materiais de construção. O dia-multa será à razão mínima, em face da situação econômica do acusado.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ ("É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"), uma vez que o réu é reincidente, mas as circunstâncias são favoráveis, pois o presente crime não envolve violência ou grave ameaça, confessou na fase extrajudicial, demonstrando arrependimento e nada foi subtraído,

pelo que a vítima não teve prejuízo. O dia-multa será à razão mínima, em face da situação econômica do acusado.

No caso em tela, o réu é reincidente e o crime é tentado, de forma que não é possível auferir o valor da "res", motivo pelo qual é incabível o furto privilegiado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação e, em consequência, CONDENO HUENOS GASPARI LIMA à pena de 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, com início no REGIME SEMIABERTO e 5 (CINCO) DIAS-MULTA à razão mínima, por se achar incurso no art. 155, § 4.º, inc. II e IV, c.c. o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Embora não seja reincidente em virtude da prática do mesmo crime, não é socialmente recomendável a substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que é reincidente pela prática de tráfico (fls. 124) e ostenta condenações posteriores, o que demonstra que não foi um fato isolado em sua vida e que não teria responsabilidade para cumprir o benefício, o mesmo ocorrendo em relação à substituição por multa. Incabível a concessão de "sursis" por ser reincidente em crime doloso (art. 77, inc. I, do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, vez que respondeu ao processo solto (fls. 77/79 – concedida liberdade provisória); observando que está preso por outro Juízo (fls. 195).

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação dos danos para a vítima (art. 387, inc. IV, do CPP com a redação da Lei n.º 11.719/08), porque não conseguiu a posse dos bens, nem há outros prejuízos materiais decorrentes do fato.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; art. 3.º, inc. II, da Lei n.º 1060/50; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, expeça-se guia de recolhimento definitiva (regime semiaberto) e providencie-se o cálculo das multas, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Diadema, 19 de outubro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA